

1502228-95.2021.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Juliana Maria Maccari Gonçalves

Comarca: Embu das Artes

Foro: Foro de Embu das Artes

Vara: 3ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 23/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2308790/2021 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 21355470 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 2195/21/404 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 2308790 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Embu das Artes

Foro de Embu das Artes

3ª Vara Judicial

Avenida Vereador Jorge de Souza, nº 855, Embu das Artes-SP - cep 06803-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502228-95.2021.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502228-95.2021.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2308790/2021 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 21355470 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 2195/21/404 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 2308790 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADRIANO APARECIDO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA MARIA MACCARI PAUFERRO

Vistos.

I - RELATÓRIO

ADRIANO APARECIDO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, pois, em 11 de novembro de 2021, por volta das 08h, na Rua Vicente de Carvalho, nº 44, Bairro Moinho Velho, nesta Comarca, guardava, para fins de entrega a terceiro, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 26 porções de "cocaína", com peso

líquido de 8,1g, 21 porções de "maconha", com peso líquido de 33,2g, 5 porções de "crack", com peso líquido de 0,6g, e 4 porções de tricloroetileno, com peso líquido de 14ml (fls. 111/112).

Consta da inicial acusatória que o réu guardava esses entorpecentes no interior de sua residência, dentro de um vaso sanitário, com a finalidade de praticar o comércio espúrio de drogas.

Determinada a notificação do acusado, o réu apresentou resposta à acusação (fls. 117/128).

A denúncia foi recebida em 24 de março de 2022, oportunidade em que se designou audiência de instrução e julgamento (fls. 133/134).

Em audiência, foram ouvidas as testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução processual, o Ministério Público requereu a integral procedência da ação penal, com a exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei de Drogas, o reconhecimento da reincidência específica, o afastamento da atenuante da confissão espontânea, assim como da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da mesma lei, bem como a imposição de regime inicial fechado.

A Defesa, por sua vez, arguiu a questão preliminar de nulidade da invasão do domicílio do acusado, por não haver prova de que houve consentimento dos moradores ou de que houvesse situação de urgência que justificasse a entrada dos policiais.

No mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a fixação da pena no menor patamar possível.

É o relatório. Fundamento e decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

A preliminar de nulidade da prova se confunde com o mérito e será a seguir analisada, devendo a ação penal ser julgada improcedente.

Trata-se, na hipótese, de acusação pelo cometimento da seguinte infração penal:

"Lei nº 11.343/06, Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa."

Pois bem.

Destaco, inicialmente, os seguintes documentos, que fundamentaram a propositura da ação penal: auto de prisão em flagrante (fls. 1), auto de exibição/apreensão (fls. 8/9), Boletim de Ocorrência (fls. 11/13), laudo de constatação (fls. 18/23) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 96/107), este último com resultado positivo para "cocaína", "maconha" e "tricloroetileno".

Além disso, houve regular produção de prova oral em Juízo.

Em seu interrogatório judicial, o réu ADRIANO APARECIDO DA SILVA negou a imputação. Disse que estava na casa de Hadassa e, de manhã, os policiais já haviam entrado em sua residência, e não sabia. Invadiram e reviraram todo o seu "barraco". Não o acharam. Então, dirigiram-se até a casa de Hadassa, e o acusado costumava dormir lá de vez em quando. Hadassa perguntou aos policiais o que estava acontecendo, e eles já apontaram o revólver para o depoente, para que continuasse sentado na cama. Reviraram o colchão, a casa. Passou algum tempo, entrou um policial no banheiro e já saiu com as drogas.

O policial civil ALMERINDO OLIVEIRA BARRETO FILHO relatou que houve notícia da ocorrência de tráfico pelo réu na região de Paraísoópolis. Segundo informações, o réu faz parte de organização criminosa. Foram até a residência do acusado, demorou um pouco para serem atendidos. A esposa do acusado abriu a porta e falou que ele poderia entrar. Houve regular identificação como policiais civis e o motivo de sua presença no local. Houve autorização de que os policiais entrassem. Ao adentrarem, viram de pronto uma sacola boiando no vaso sanitário, com alguns "eppendorfs". O réu admitiu a propriedade das drogas. Após, o réu foi conduzido à Delegacia de Polícia para que se tomassem as medidas necessárias. Na sacola havia maconha, lança perfume e cocaína. Não havia tampa nem descarga no vaso sanitário. Receberam uma ordem de serviço solicitada pelo Delegado da 89ª DP, para qualificar o réu

presente, que estava sendo investigado como autor do tráfico de entorpecentes na região de Paraisópolis. Participou também da diligência o policial Renan, e cerca de outros seis policiais.

No mesmo sentido, as declarações do policial civil RENAN HENRIQUE COSMO DE OLIVEIRA, que também participou da diligência. Disse que a "ordem de serviço" dizia que o réu era responsável por levar drogas a Paraisópolis, então deveriam qualificar o réu e levá-lo para ser ouvido perante as autoridades. Informalmente, o réu disse que a droga era sua no momento da apreensão, assumindo o crime de tráfico na oportunidade. Não há testemunhas dizendo que poderia entrar na residência. Não sabe dizer se a ordem de serviço é referente a algum inquérito policial ou não. Ora, dos depoimentos colhidos em Juízo, se verifica de forma inconteste que a diligência que levou à apreensão dos entorpecentes descritos na denúncia foi realizada de forma ilegal, sem mandado e sem que houvesse qualquer suspeita de flagrante delito.

Ambos os policiais civis foram uníssomos ao afirmar que se dirigiram à residência munidos de uma "ordem de serviço", destinada a qualificar o acusado, em razão de uma informação anterior de que ele estaria traficando na região de Paraisópolis, inclusive com envolvimento em organizações criminosas.

Ocorre que tal "ordem de serviço" não se confunde com mandado judicial, para que se configure o requisito de determinação judicial previsto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Questionados, os policiais sequer souberam informar se a tal "ordem de serviço" estava vinculada ou não a algum inquérito em andamento, formalmente instaurado pela autoridade policial. Também não houve prova documental nesse sentido.

Também inexistiu qualquer evidência de que havia fundada suspeita de flagrante delito. O réu estava na residência de sua companheira e, ao que tudo indica, os policiais civis se dirigiram até lá por possuírem informação de que o réu praticava a traficância na região de Paraisópolis, com a finalidade de identificá-lo. Ou seja, sequer havia suspeita de que estivesse, naquele momento, guardando drogas na residência em questão, que sequer era sua, uma vez que a finalidade da dita "ordem de serviço" era apenas realizar a sua identificação pessoal.

Por fim, também não restou suficientemente demonstrado que houve autorização para a entrada dos policiais na casa.

Destaco, nesse sentido, o recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a prova do consentimento do morador deve ser suficientemente idônea, sob pena de violação ao disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.. No julgamento do HC 686.489/SP, relatado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, da 5ª Turma, e julgado em 19 de outubro de 2021, se indicou que a prova do consentimento deve se dar, preferencialmente, por declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, apontando-se, sempre que possível, testemunhas do ato, além de ser registrada em áudio-vídeo, e preservada tal prova enquanto perdurar o processo.

Sobre o tema, confira-se, ainda os seguintes julgados, proferidos pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. 1. Preliminar. Violação à garantia da inviolabilidade domiciliar. 1.1. A inviolabilidade do domicílio mereceu, por parte do legislador constituinte, a devida tutela no contexto dos direitos fundamentais (artigo 5º, inciso XI, Constituição Federal). Trata-se de corolário do direito à privacidade, figurando, dessa forma, como a sua garantia. A inviolabilidade, contudo, não possui contornos absolutos tendo o próprio legislador indicado as hipóteses excepcionais de sua restrição. 1.2. O ingresso regular na casa alheia depende da convergência de justa causa. A situação de flagrante deve ser indicada ou deduzida pelas circunstâncias fáticas, sob pena de se admitir que invasões arbitrárias possam ser tomadas sacrificando-se a garantia constitucional. Precedentes do STJ e do STF. 1.3. Hipótese em que os elementos fáticos não autorizavam a afirmação de justa causa para o ingresso na residência. Narrativas apresentadas pelos policiais militares que se contrapõem aos relatos fornecidos pelas testemunhas de defesa, que relataram contexto de ingresso forçado na residência não amparado por justa causa. Consentimento não comprovado. 2. A mera

presença de denúncias anônimas indicando o envolvimento da acusada com o tráfico de drogas não servem para demonstrar a justa causa necessária para o ingresso domiciliar forçado. Precedentes do STJ. 3. Ilícitude probatória reconhecida. Afirmação da inadmissibilidade das provas obtidas durante a busca e reconhecimento dos efeitos contaminatórios. Absolvição de rigor, nos termos do art. 386, inciso V, do CPP. 4. Recurso conhecido e provido." (Apelação Criminal nº 1500394-98.2021.8.26.0291, rel. Des. Marcos Alexandre Coelho Zilli, 16ª Câmara de Direito Criminal, j. 08.08.2022).

"Apelação. Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo e munições. Pleito objetivando a ilicitude das provas obtidas a partir de denúncia anônima e posterior ingresso em domicílio, por policiais militares, com a consequente absolvição por falta de provas. Possibilidade. Apelante que teria mantido em depósito 95 porções de crack (11,59 g), 12 porções de cocaína (3,97 g) e 29 porções de maconha (55,99 g), para fins de traficância, bem como possuía um revólver, calibre 38, com numeração suprimida, municiado com cinco cartuchos intactos, e cinco munições, calibre 38, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Ilegalidade da atuação policial no caso concreto. Diligência policial iniciada por meio de "denúncia anônima" genérica, não esclarecida quanto à sua origem e existência. Entrada na residência da recorrente que ocorreu sem nenhuma diligência prévia de investigação policial, como o acompanhamento do movimento no imóvel por meio de campanas, com registro documental, ou mesmo o flagrante de uma atividade de mercancia ilícita, não se demonstrando sequer a urgência necessária para a excepcional invasão da residência naquele momento específico por parte dos policiais militares. Dúvidas acerca da existência e regularidade do suposto consentimento oferecido pela apelante, quanto à entrada dos policiais no local. Circunstâncias do caso concreto que, em seu conjunto, demonstram a ilicitude da entrada dos policiais no apartamento da recorrente e, por consequência, da apreensão dos entorpecentes, da arma de fogo e respectivas munições. Precedentes do STF e do STJ. Assim, tendo em vista a inadmissibilidade de utilização de tais elementos de prova ilícitos, resta frágil e insuficiente o acervo probatório amealhado para comprovação dos crimes, sendo de rigor a absolvição da apelante, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP. Recurso provido." (Apelação Criminal nº 1500037-10.2021.8.26.0618, rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, 16ª Câmara de Direito Criminal, j. 07.08.2022).

No caso em apreço, além de não haver qualquer registro idôneo desse consentimento, a única testemunha presencial do ato, Hadassa Mirian Rangel de Sousa Barros Januário, não foi arrolada como testemunha na fase processual. De todo modo, em seu depoimento policial (fls. 04), não há notícia ou declaração expressa quanto a seu consentimento para entrada na residência. Pelo contrário: nada disse acerca de seu consentimento para a entrada dos policiais.

E presumir o consentimento da moradora, sem que haja qualquer evidência nesse sentido, tornaria inócua a garantia constitucional prevista no art. 5º, inciso XI, da Carta Magna, esvaziando um dos princípios basilares de nosso Estado Democrático de Direito: o direito fundamental relativo à inviolabilidade de domicílio. Ressalto que a ilegalidade da atuação policial já havia sido reconhecida em sede de audiência de custódia, o que ensejou, inclusive, o relaxamento da prisão em flagrante do réu, com a consequente expedição imediata de alvará de soltura (fls. 41/46).

E, afastada a apreensão ilegal dos entorpecentes, nada resta em desfavor do acusado a amparar eventual condenação, sendo de rigor, portanto, sua absolvição por insuficiência probatória.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal, a fim de ABSOLVER o acusado ADRIANO APARECIDO DA SILVA da acusação que lhe foi imputada, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Como não houve a decretação da prisão preventiva nestes autos, e permanecendo ausentes, ademais, os requisitos deste decreto cautelar, autorizo que o réu aguarde o julgamento de eventual recurso em liberdade.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, anotando-se a extinção.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.
Embu das Artes, 23 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA